

1500384-06.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... e 714 dias-multa, referente ao delito de tráfico ilícito de drogas, e 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 1000 dias-multa referente ao delito de associação para o tráfico; e para RAFAEL, em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas e em 3 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 900 dias-multa quanto ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500384-06.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-06.2021.8.26.0598 - Controle 2021/002089

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA e outros

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2296804/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21129162 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 338/21/204 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2296804 - DEL.POL.BOCAINA, 338/21/204 - DEL.POL.BOCAINA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

ANDRÉIA ZACARIAS DE JESUS, GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA e RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, porque, em período incerto, mas ao menos desde o mês de setembro de 2021 até o dia 29/10/2021, em vários locais da cidade de Bocaina, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos, associaram-se, de maneira estável e duradoura, com o adolescente inimputável S.S.O. (à época com 16 anos - fls. 89), para praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas; ademais, porque, aos 29/10/2021, por volta das 9h15min, na Rua Virgílio de Carvalho, n.º 358, no centro daquela cidade, agindo em concurso e com unidade de propósitos, entre si e com o adolescente sobredito, guardavam, para fins de tráfico, 57,98 gramas de maconha (47 porções), 50,94 gramas de cocaína (61 porções) e 80,90 gramas de crack

(20 porções), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram detidos em flagrante (fls. 1/2) e, dispensada a realização da audiência de custódia (Comunicado nº 232/2020 da E. Corregedoria-Geral da Justiça), tiveram a prisão convertida em preventiva, aos 30/10/2021 (fls. 151/5), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 187/203).

Contudo, em sede de habeas corpus, RAFAEL obteve liberdade provisória cumula com medidas cautelares diversas, aos 09/12/2021 (fls. 324/7), que foi cumprida aos 16/12/2021 (fls. 340/1).

Regularmente notificados (fls. 370, 372 e 375), os réus ofereceram respostas escritas à acusação (fls. 346/63), após o que a denúncia foi recebida, em 27/01/2022 (fls. 380/3).

Em instrução, ouviram-se oito testemunhas, interrogando-se os réus ao final. Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou pela parcial procedência da ação penal, com condenação de RAFAEL e GABRIEL, bem como absolvição de ANDRÉIA por falta de provas (fls. 491/3 e 505).

Já a Defesa comum, preliminarmente, alegou nulidade dos atos praticados pelos policiais e, no mérito, sustentando a ausência de provas, inclusive quanto à existência de vínculo para o crime de associação, protestou pela absolvição; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06 e teceu ponderações acerca da aplicação da pena (fls. 497/504). É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade formulada pela Defesa. Com efeito, conforme se infere dos depoimentos colhidos em Juízo, verificou-se que a conduta policial não se baseou unicamente em delações apócrifas, mas em efetiva investigação realizada pela Polícia Civil. Assevere-se que, ouvidos em Juízo, confirmaram os Policiais que, antes da realização da busca, foram por diversas vezes até às residências que eram os locais do fato. Dessa forma, havendo medidas anteriores conduzidas na investigação, não há nulidade a ser reconhecida.

Passando ao mérito, a demanda é parcialmente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), fotografias das drogas e bens apreendidos (fls. 84 e 86/102), laudo de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 103/14), pela Informação nº 55/2021 (fls. 4/14 dos autos dependentes nº 1503591-28.2021.8.26.0302), pelos laudos dos bens apreendidos (fls. 256/78) e, por fim, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 250/5 – foi detectada a presença das substâncias COCAÍNA, CRACK e THC [Tetrahidrocannabinol]).

Autorias e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em declarações ao Juízo, o Policial Civil Plínio que diligenciou no caso foi firme e coerente em confirmar os fatos como trazidos pela denúncia, destacando que os irmãos GABRIEL, RAFAEL e S.S.O. (todos filhos de ANDRÉIA) estavam sendo investigados há tempos pelo setor de investigação, inclusive com a realização de campanas; foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na casa deles, mas nada de ilícito foi encontrado, mesmo havendo informações de que estavam traficando; em setembro/outubro de 2021, houve delação apócrifa no sentido de que eles estariam guardando droga na casa ao lado; então, foi pedido e deferido um mandado de busca e apreensão para a casa deles e para o imóvel em que estaria a droga; em diversas ocasiões, viu usuários entrando e saindo, com movimentação típica de “biqueira”; chegou a ver pessoas andando por cima do muro onde dava acesso à casa em que as drogas estavam guardadas; lembrou-se de ter visto GABRIEL, ANDRÉIA e o adolescente S.S.O. no local, mas não pode dizer o mesmo quanto a RAFAEL; viu que GABRIEL e ANDRÉIA ficavam na parte de fora atendendo pessoas, as quais o depoente sabia que eram usuários de droga; no dia do fato, GABRIEL, ANDRÉIA e o adolescente S.S.O. não quiseram se pronunciar; RAFAEL foi ouvido pela Polícia e confessou ser o proprietário de toda a droga; em certa oportunidade, um usuário, que fizera um boletim de ocorrência, falou que os réus (sem maiores explicações) mantinham uma “biqueira” e que escondiam droga em local vizinho; também foram

encontrados “sacolés”; quando do cumprimento do mandado no imóvel situado ao lado da casa dos réus, houve apreensão de maconha e, em outro lugar, a cocaína (dentro de uma máquina quebrada de lavar roupas), bem como, no banheiro da casa abandonada, uma balança de precisão e porções de crack e cocaína; havia dinheiro com GABRIEL, ANDRÉIA; nenhum dos réus disse que trabalhava e tampouco indicaram a origem do dinheiro para aquisição dos veículos (duas motos e um carro); o muro que dividia os imóveis era alto e de difícil acesso, porém, pela frente da casa onde a droga foi encontrada, havia um muro mais baixo e com um portão de fácil escalada; na imóvel em que a droga estava, não foi encontrada nada que a ligasse aos réus (como roupas ou outros pertences); a associação dos réus não é recente, pois Rafael e o adolescente já eram investigados por tráfico ilícito de drogas pela Polícia Civil. No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Elcio, o qual acrescentou que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma motocicleta com duas pessoas saiu de maneira rápida, portando uma sacola; já conhecia os réus anteriormente; as delações apócrifas informavam a existência de drogas, inclusive que o tráfico era perpetrado por ANDRÉIA; nenhum dos réus trabalhava, mas possuíam duas motocicletas e um automóvel.

A testemunha Chirlei afirmou que é tia dos réus e que RAFAEL é usuário de drogas, mas nunca ouviu dizer nada sobre o tráfico propriamente; RAFAEL fazia “bicos” como servente de pedreiro; GABRIEL trabalhava, às vezes, com a mãe dele na roça; não soube dizer se eles tinham carro.

Já a testemunha Lucas disse que RAFAEL é sobrinho de sua esposa (“Andressa”), porém não tem conhecimento de nada que o desabone; RAFAEL trabalhou com um seu amigo, como servente de pedreiro.

Por sua vez, a testemunha Taís, esposa de RAFAEL, disse que sempre teve pouco contato com GABRIEL, pois não morava na mesma casa que ele; RAFAEL trabalhava como servente juntamente com “Gilvan” (um amigo da família); à época, morava com sua genitora e com RAFAEL; no local dos fatos, moravam ANDRÉIA, GABRIEL e S.S.O.; RAFAEL tinha saído do local há aproximadamente seis ou sete meses e não costumava ir lá; no dia dos fatos, ele estava trabalhando e, quando ficou sabendo da diligência, dirigiu-se ao local; ele não usava drogas e tampouco sabia que ele as vendia; acredita que GABRIEL era usuário de drogas.

A testemunha Alexsandra, amiga de ANDRÉIA, relatou que a conhecia há oito anos, pois chegou a trabalhar com sua genitora; não tem conhecimento de nada que a desabone; ANDRÉIA trabalhava na roça.

A testemunha Andressa, irmã de ANDRÉIA, afirmou que não tem conhecimento do envolvimento desta com atividades criminosas, porque sempre foi trabalhadora; à época dos fatos, porém, ela estava desempregada; apenas GABRIEL morava com ANDRÉIA; RAFAEL morava com a esposa dele; não soube dizer se GABRIEL trabalhava; RAFAEL trabalhava em um curtume.

Já a testemunha Camila, amiga de ANDRÉIA, disse que a conhece há três ou quatro anos; não tem conhecimento se ela tem envolvimento com atividades criminosas; à época, ela trabalhava.

Formalmente interrogada, ANDRÉIA negou o cometimento dos crimes, aduzindo que não sabia da existência de drogas no local e tampouco quem seria o proprietário delas; parou de trabalhar cerca de um mês antes dos fatos; morava com seu marido (“Maicon”), S.S.O. e GABRIEL; já RAFAEL morava na casa da esposa dele; não tem conhecimento da venda de drogas no local; como estava desempregada, ficava na sua casa durante o dia; uma motocicleta e o veículo “Gol” eram de GABRIEL, que trabalhava, algumas vezes, como servente de pedreiro; S.S.O. tinha uma motocicleta, a qual foi adquirida com dinheiro do pai dele; seu marido tinha um veículo “Monza”, em cujo nome não estava, mas tinha documento; seu marido também estava na casa no dia da diligência, foi conduzido à Delegacia de Polícia, mas não foi preso; seus três filhos usam drogas; ouviu comentários de que RAFAEL assumira as drogas.

GABRIEL negou também negou a prática dos delitos, sustentando que não sabia da existência das drogas no local; outras pessoas vendiam droga no imóvel, tanto que já as viu entrando lá; trabalhava com curtume, mas sem registro; tinha um veículo “Gol” e uma motocicleta, que foram adquiridos parceladamente de um amigo; ganhava cerca de R\$ 400,00 por semana (R\$ 80,00 por dia) e, quando trabalhava aos sábados,

auferia mais R\$ 80,00; à época dos fatos, estava trabalhando; morava com ANDRÉIA e com S.S.O.; “Maicon” ficava a maior parte do tempo lá, mas não moravam juntos; soube que RAFAEL, na Delegacia de Polícia, assumiu a propriedade das drogas, mas acredita que ele o fez após ter visto seus familiares algemados.

Por fim, RAFAEL afirmou que ANDRÉIA sempre trabalhou, mas estava desempregada ultimamente; assumiu a propriedade das drogas ao ver seus familiares algemados; somente nas dependências da Delegacia de Polícia ouviu dizer que encontraram as drogas; sustentou não ter dito a verdade quando formalmente ouvido; já fazia um tempo que morava com sua namorada; não tinha veículos e não informou a senha de acesso do seu celular aos Policiais; GABRIEL já trabalhou, mas não soube precisar o período; nunca o viu usando drogas.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que os réus GABRIEL e RAFAEL cometeram conjuntamente os crimes imputados, pois as suas versões, já inconsistentes de per si (dentre o mais, o primeiro quis fazer crer que não sabia da existência das drogas no local, mas depois disse que outras pessoas vendiam drogas lá, tanto que já as viu entrando e saindo; já o segundo sustentou que somente admitiu a propriedade das drogas, porque viu os seus familiares algemados, bem como que só viu as drogas nas dependências da Delegacia de Polícia), permaneceram destoantes do contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque, a confissão extrajudicial de RAFAEL (no sentido de que adquiria as drogas na cidade de Pederneiras e que promovia o tráfico de drogas há aproximadamente seis meses, bem como que utilizava o imóvel vizinho para guardá-las [fls. 8]) e os informes do Policiais mostraram-se compatíveis com o que fora narrado pela denúncia e reproduzido sob o crivo do contraditório, inclusive no que tange à Informação nº 55/2021 (fls. 4/14 dos autos dependentes nº 1503591-28.2021.8.26.0302), no sentido que ao menos os réus GABRIEL e RAFAEL, juntamente com o adolescente inimputável S.S.O. (à época com 16 anos – fls. 89), começaram a promover o tráfico ilícito de drogas na residência em que residiam (Rua Virgílio de Carvalho, n.º 338, no centro da cidade de Bocaina), bem como a guardar drogas na residência de nº 358, a qual era vizinha e estava desocupada. Ademais, o Policial Civil Plínio também confirmou que, no mês de setembro de 2021, a Delegacia de Polícia de Bocaina começou a receber diversas informações anônimas naquele sentido e que o local era frequentado, nos períodos diurno e noturno, por diversos indivíduos conhecidos por serem usuários de drogas.

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação – ressaltando que nem os próprios réus conseguiram sequer conjecturar alguma hipótese plausível para tanto –, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020). Até porque, como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. No caso, não haveria, nem foi apontada, razão plausível para que incriminassem o réu injustamente (Apelação Crime Nº 70045139300, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 21/03/2012).

Considere-se, no mais, que a quantidade e a forma em que as drogas foram encontradas (17 porções de crack envoltas em plástico branco [55,87 gramas – fls. 92, 94/5 e 253], 64 porções de cocaína contidas em microtubos e em embalagem plástica [21,93 gramas – fls. 93/5 e 253/4] e 47 porções de maconha embaladas em plástico transparente [11,11 gramas – fls. 94, 96 e 254]), a apreensão de apetrechos sabidamente utilizados para o manuseio e embalagem de drogas (1 balança de precisão 15 microtubos do tipo eppendorf e 40 embalagens plásticas transparentes

[fls. 256/65]), de dinheiro, veículos e motocicletas sem comprovação de origem lícita (R\$ 414,00 em cédulas de valores variados [fls. 266/79]), convergem à conclusão de que os fatos se ajustam mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de guardar drogas). E mais, também ao do art. 35 da mesma lei.

Lembre-se, ainda, de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318). Ademais, confira ainda esta pontual lição doutrinária: Todavia, nem sempre é possível a prova direta desses fatos específicos, ora porque foram clandestinos, ora porque são subjetivos, ora porque a prova direta pereceu ou é impossível. Nesses casos o labor probatório se desenvolve com prova indireta, cujo objeto são fatos que não estão previstos na lei com geradores de consequências jurídicas, mas que podem levar à conclusão sobre a existência daqueles fatos legalmente relevantes para se alcançar o resultado pretendido. Esses fatos, objeto da chamada prova indireta, são os indícios, que se conceituam como fatos ou circunstâncias de fato que podem levar à conclusão da existência de outros fatos.

[...] verifica-se que entre a prova do indício e a convicção da existência do outro fato, o juiz, mentalmente, dá um salto, através de um raciocínio lógico, mediante a aplicação de 'presunções' ou 'regras de experiência'. [...] No primeiro caso, a convicção da existência resulta de imposição legal. No segundo, da aplicação de uma regra que o juiz extraiu da observação técnica ou da observação do que ordinariamente acontece no comportamento humano. [...] As regras de experiência, comum ou técnica, não estão no plano dos fatos e, portanto, do ônus da prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, como faria com as presunções legais, podendo, contudo, a parte ter interesse em desenvolver atividade argumentativa sobre tais regras, como faria juntando pareceres jurídicos sobre a interpretação do direito, mas nesse caso não se trata, propriamente, de atividade probatória, mas apenas de atividade dialética de argumentação e colaboração. [...] As presunções que decorrem das regras da experiência, quer a técnica, quer a comum, admitem prova em contrário, ou seja, as partes podem pretender demonstrar que certo fato não tem o significado que parece ter ou que ordinariamente teria. Todavia, o ônus de demonstrar essa peculiaridade é de quem pretende desfazer a conclusão que naturalmente decorreria. [...] (GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 208, 209 e 211 e 212).

É então de se assentar, também, que mesmo em casos nos quais as negociações sobre o comércio de drogas tenham sido esporádicas ou menos frequentes, ainda assim a conduta pode se subsumir ao tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06, pois o realmente relevante é a estabilidade do vínculo associativo, ou seja, um liame para além do meramente ocasional, efêmero e, por isso, um efetivo animus associativo. A propósito, confira a abalizada doutrina: [...] Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a ser concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29). [...] (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Penal Especial Comentada: Volume Único - 6. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2018, pg. 1048).

Nesse mesmo sentido, a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação

criminosa. [...] (HC 596.946/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). E mais: [...] A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas. 3. As instâncias ordinárias embasaram a condenação dos pacientes em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais -, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que os réus integrariam, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. [...] (AgRg no HC 618.503/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Assim, pela conjugação de todos esses elementos de convicção, não há dúvida de que os réus GABRIEL, RAFAEL e ao adolescente S.S.O. associaram-se, de forma estável e permanente, não estanque ou sob mera coautoria, para a prática do tráfico ilícito de drogas, formando uma verdadeira *societas sceleris* para essa finalidade. Isso porque, frise-se, toda a prova também demonstrou - com coerência e coesão entre todos os meios por que reproduzida sob o contraditório, robustez e consequente segurança - que não houve um encontro meramente fortuito entre eles, mas sim porque todos agiam em conjunto.

De mais a mais, não há que se falar na desclassificação do delito de tráfico para o de uso compartilhado (parágrafo 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), o qual exigia que o agente ofereça a droga em caráter eventual, sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem, requisitos cumulativos estes que não ficaram demonstrados nos autos. A propósito, confira a abalizada doutrina: [...] Sobre o tema, também merece destaque a lição de: "Para a ocorrência da situação prevista no parágrafo, de pena substancialmente menor, há necessidade de três circunstâncias objetivas e uma subjetiva. As duas primeiras objetivas são: que o oferecimento seja eventual e, cumulativamente, que não tenha objetivo de lucro. Ambas são necessárias concomitantemente, de modo que a ausência de uma exclui o privilégio, uma vez que oferecer fora dessas circunstâncias caracteriza o crime do caput. [...] Quanto ao tipo de relacionamento a ser relevante, caberá ao juiz defini-lo no caso concreto, mas deve ser de natureza pessoal, ou seja, de molde a propiciar a intimidade suficiente para o consumo conjunto. [...] A circunstância subjetiva é o dolo específico, consistente no fim de juntos consumirem a droga, o que pode, eventualmente, não ocorrer, porque para a caracterização da forma privilegiada basta o fim, cuja prova também dependerá de aspectos objetivos circunstanciais a serem observados." [...] (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada: Lei nº 11.343/2006. São Paulo, Saraiva, 2007, p. 100/101).

Por outro lado, a simples alegação de que os réus GABRIEL e RAFAEL seriam (somente) usuários de drogas não tem o condão de eximi-los (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, faziam, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse odioso vício (inclusive porque caro e, repita-se, sem comprovação por eles de renda lícita suficiente para tanto [fls. 21, 23/4 e 26], destacando-se que a cocaína é tida como a droga consumida pelas pessoas de mais alto poder aquisitivo) com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde

pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Tal desfecho condenatório não deve alcançar, contudo, a corré ANDRÉIA, tendo em vista que a sua autodefesa foi em parte confirmada pelas testemunhas de defesa, as quais foram uníssonas em afirmar que ela era uma pessoa trabalhadora e que apenas permaneceu desempregada cerca de um mês antes da realização da diligência, bem que iria logo voltar a exercer função lícita. Além disso, o laudo pericial de extração de dados de celular (cujo link de acesso se encontra às fls. 489/90) nada de mais substancioso ou comprometedor destacou quanto à corré, havendo apenas mensagens corriqueiras e/ou quotidianas trocadas com amigos e familiares.

Nessa linha de raciocínio, então, embora seja possível que ANDRÉIA estivesse mesmo associada aos demais corréus para a prática do tráfico ilícito de drogas (relembrando os dizeres dos Policiais que autuaram no caso), o conjunto probatório não se mostrou suficiente coeso, robusto e seguro quanto a esse fato e, apesar das evidências trazidas da fase inquisitiva, mas não confirmadas sob o contraditório, a dúvida que se encerra deve ser resolvida em benefício de ANDRÉIA, dado o secular princípio que rege a causa penal nesta fase processual. Até porque não vislumbro outras provas presenciais e/ou suficientes que pudessem ser produzidas em Juízo.

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor as condenações apenas em relação aos GABRIEL e RAFAEL, passo à dosimetria das suas respectivas penas, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a circunstância do delito em razão da variedade (maconha, crack e cocaína) e natureza das drogas apreendidas (crack [esta última sabidamente uma das substâncias ilícitas mais caras e de especial capacidade destrutiva]), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado; ademais, deve ser considerada a personalidade de GABRIEL, pois cometeu os crimes enquanto usufruía do benefício de prestação de serviços à comunidade (fls. 118 – Processo nº 3531/19 [TJ aos 10/07/2020]), evidenciando total menosprezo com a seriedade da lei e da Justiça.

Diante de tudo isso, as penas-base reclamam ser exasperadas, pois o mais proporcional ao quanto analisado, resultando, para GABRIEL, em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa, referente ao delito de tráfico ilícito de drogas, e 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 1000 dias-multa referente ao delito de associação para o tráfico; e para RAFAEL, em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas e em 3 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 900 dias-multa quanto ao delito de associação para o tráfico, mas todos com os dias-multa calculados sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica deles (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, em virtude da menoridade relativa e da confissão extrajudicial de RAFAEL quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas (CP, art. 65, I, 1ª parte, e III, d), aplico-lhe o decréscimo de 2/6 em relação ao delito de tráfico ilícito de drogas e de 1/6 em relação ao crime de associação para o tráfico, como o mais proporcional ao quanto reconhecido, mas sem repercussão prática no que se refere ao primeiro delito, em razão do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no mínimo legal. No mais, em razão da reincidência de GABRIEL (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme certidão de fls. 118 (Processo nº 3531/19 – TJ aos 10/07/2020), aplico-lhe o acréscimo de 1/6, pois o mais condizente ao quanto reconhecido. Então, redimensiono as penas de GABRIEL em 8 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 833 dias-multa, quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas, e em 4 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão e 1166 dias-multa quanto ao delito de associação para o tráfico; e as de RAFAEL em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas, e em 3 anos, 2 meses e 16 dias de

reclusão e 750 dias-multa quanto ao delito de associação para o tráfico. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem observadas, tampouco a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois em evidente incompatibilidade objetivo-subjetiva com o crime autônomo de associação e com a reincidência de GABRIEL, frisando-se, ainda, porque o tráfico sob análise não se tratou, em absoluto, de algo isolado, eventual ou meramente incipiente a que visa o enfocado benefício legal (lembre-se de que, afora a Informação nº 55/2021 [fls. 4/14 dos autos dependentes nº 1503591-28.2021.8.26.0302], o Policial Civil foi categórico em afirmar que havia informações anônimas de que os réus GABRIEL e RAFAEL estavam promovendo conjuntamente o tráfico ilícito de drogas há considerável período de tempo; no mais, destaque-se o histórico de RAFAEL, que admitiu ao Juízo ter sido adolescente infrator por ato equiparado a furto qualificado, tendo cumprido medida socioeducativa de liberdade assistida [fls. 126], sendo certo que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes [STJ, AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020]). Saliente-se também que tal benesse deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (TJSP, Apelação Criminal nº 0002486-09.2007.8.26.0326; Relator: Luiz Antonio Cardoso; 3ª Câmara de Direito Criminal; julgamento: 25/05/2010). E em razão do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (envolver adolescente [S.S.O., à época com 16 anos - fls. 89]), aplico o aumento de 1/6 a ambos os réus, pois o mínimo proporcional a uma só causa. Então, torno definitivas as penas de GABRIEL em 9 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão e 972 dias-multa, referente ao delito de tráfico ilícito de drogas, e em 5 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão e 1360 dias-multa referente ao delito de associação para o tráfico; e de RAFAEL em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, referente ao delito de tráfico ilícito de drogas, e em 3 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão e 875 dias-multa, referente ao delito de associação para o tráfico. Como os réus, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes diferentes (itens 1 e 2 da denúncia), portanto, em concurso material (CP, art. 69, caput), aplicam-se cumulativamente as penas.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e art. 33, § 2º, a, do CP, os réus devem iniciar o cumprimento das penas no regime fechado (CP, art. 34), até porque é o único que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso, destacando-se o analisado na dosimetria como um todo e, assim, também como ilustra a jurisprudência: [...] Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Regime fechado - Possibilidade - Recurso do Ministério Público provido (TJSP, 4ª Câmara Criminal Extraordinária - APL 00228096120128260196 SP, Rel. Alexandre Almeida, julgamento 25/03/2015, publicação 30/03/2015).

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o que apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 18/20 e 279), inclusive os veículos descritos pela denúncia e no RDO (fls. 13/17, 88, 90 e 98/102), até porque a lei específica determina sempre a perda dos veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes por ela definidos, ou seja, independentemente de consistirem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção também constituir ilícito de per si. Consigne-se, ainda, que segundo entendimento do STF (RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/05/2017), é possível o perdimento de qualquer bem de valor econômico apreendido em razão do tráfico de drogas, sendo desnecessária a habitualidade, a modificação e/ou a reiteração do uso do objeto, os quais não são pressupostos para o confisco dos bens apreendidos (v. informativo 865 do STF). Além disso, saliente-se que os veículos tratados foram encontrados na residência dos réus quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva deste processo, de modo que tudo também converge à constatação de que os veículos foram adquiridos com a renda auferida com a traficância (produto desta); ressalte-se, porque os réus

GABRIEL e RAFAEL não produziram nenhuma prova eficaz e segura (tão somente a não isenta versão de ANDRÉIA de que uma motocicleta e o veículo "Gol" eram de GABRIEL, que trabalhava, algumas vezes, como servente de pedreiro, bem como de que S.S.O. tinha uma motocicleta, a qual foi adquirida com dinheiro do pai dele) de que também trabalhariam como servente de pedreiro e em um curtume, respectivamente. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de:

a) ANDRÉIA ZACARIAS DE JESUS, qualificada nos autos, para absolvê-la das imputações trazidas pela denúncia e com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se-lhe, prontamente, o alvará de soltura clausulado.

b) GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA e RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, para condená-los, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas, respectivamente, de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 2.332 (dois mil, trezentos e trinta e dois) dias-multa (GABRIEL), e de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa (RAFAEL), em regime inicial fechado e com o dia-multa calculado sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para ambos os réus.

Deixo de reconhecer ao réu GABRIEL o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Assim, recomende-se ele na prisão e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução. Respondendo a este processo em liberdade por R. Decisão de Egrégia Instância Superior (fls. 324/7), reconheço a RAFAEL o direito de assim permanecer em caso de apelação.

Decreto ainda o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 18/20 e 279) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 02 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA